

1500585-96.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... reincidência dos agentes, afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao crime do art. 33, §10, da Lei de Drogas, fixo para cada um dos acusados a pena-base no mínimo legal, perfazendo 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que elevo para 6 anos de reclusão e 500 dias-multa pela reincidência de ambos, ficando afastado o trafico privilegiado pelos maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1500585-96.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500585-96.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALEFF MONTEIRO DE MOURA e outros

Nesta data pelo excesso de feitos em tramite neste juízo.

Vistos.

WALEFF MONTEIRO DE MOURA e ARIIVALDO APARECIDO DE SOUZA foram denunciados como incurso nas penas do art. 33 e art. 33, § 10, da Lei 11.343/06, porque, em 15/07/2021, na Av. Emilio Bosco, 1980, e na Rua Santo Alonso, 41, ambos nesta cidade, respectivamente, teriam transportado e fornecido, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física e produtos químicos destinados 'a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os réu foram citados e apresentaram defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a audiência de instrução foi produzida prova oral, tendo sido os réus interrogados.

As partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público requerido a condenação dos réus pelo crime descrito na denúncia, posto entender comprovadas a materialidade delitiva e a autoria; a defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento de nulidade processual, pela absolvição pela insuficiência probatória e, de forma subsidiária, pela concessão dos benefícios legais.

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados. D E C I D O:

Rejeito as preliminares.

A determinação do esclarecimento pericial sobre a natureza do laudo produzido, ante a alegação de uma das partes, tal como o determinado a fls. 509, evidentemente está amparada nos expressos termos do art. 156, II, do Código de Processo Penal, ficando afastada qualquer nulidade neste sentido.

A investigação preliminar pela polícia judiciária com a realização de diligências investigativas, dentre elas campanas e oitivas informais de pessoas, visando corroborar informações anônimas recebidas, previamente à abertura de inquérito policial formal é lícita e visa justamente impedir a abertura de inquérito policial, e seus deletérios efeitos contra investigados, de forma temerária.

Neste sentido, "Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal. Precedentes." (STJ - RHC 67.566/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

Por outro lado, reconheceu o C. Supremo Tribunal Federal que: "A denúncia anônima, embora insuficiente a respaldar, por si só, o deferimento de medidas invasivas, viabiliza diligências prévias voltadas a apurar a veracidade. As peças que instruem o processo (folha e-STJ 564) revelam que, após o recebimento da notícia apócrifa, foram realizados monitoramentos, por meio dos quais levantados indícios de o recorrente estar armazenando, na residência, armas e drogas. Verifica-se não lastreada a busca e apreensão apenas na denúncia anônima, uma vez precedida de diligências." (STF - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 161.146 - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 22 mar. 2021).

Assim, a busca realizada neste procedimento investigatório preliminar é lícita, mesmo que fundada a investigação preliminar em denúncia anônima.

Para a busca domiciliar/pessoal a polícia depende da existência de fundadas razões para a legitimar o meio de prova, conforme dispõe o art. 240 do Código de Processo Penal, sendo certo que a exigência do modelo probatório relativo a estas fundadas razões pela polícia deve ser modesto, para ser compatível com a fase de obtenção de provas própria da diligência policial (STF - RE 603.616/RO - rel. Min. Gilmar Mendes - DJe 10 mai. 2016). Assim, esta análise das fundadas razões deve estar embasada em um standard probatório reduzido, a fim de permitir o justo equilíbrio entre a eficiência da persecução penal e a garantia da privacidade do cidadão, ao contrário do pretendido standard elevado e inalcançável pretendido pela defesa.

In casu, as campanas realizadas por vários dias e as demais diligências

investigativas (fls. 263/292), bem como a identificação de material repassado a um dos investigados pelo possuidor de imóvel, com a posterior e próxima abordagem do material entorpecente com a pessoa que recebeu o material do possuidor preenchem o standard probatório necessário para legitimar a busca realizada, que, portanto, é válida e produz seus efeitos de direito.

Como reconhece o C. Supremo Tribunal Federal: " a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). "(STF - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 215.906 G - Rel. Min. Rosa Weber - j. 25 mai. 2022).

Não se configurou, pois, qualquer ilicitude na prova.

No mérito, a ação penal merece prosperar.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 9/10, em que se descreve o material apreendido na posse do réu. Por outro lado, o exame químico-toxicológico revelou consistir parte da substância apreendida com os acusados em entorpecente, concluindo, pois, por sua toxicidade e potencialidade para causar dependência, bem como em produtos químicos destinados à preparação de drogas - cafeína e lidocaina (fls. 551/552). Assim, a materialidade delitiva foi comprovada.

É de se registrar que não há falar em atipicidade da conduta se o acusado foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaina e cafeína, matérias-primas utilizadas na preparação de drogas como adulterante e diluente do pó de cocaína. (STJ - AgInt no REsp 1655319/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017).

Análise a autoria delitiva.

Com efeito, o policial MARCIO OLIVIO PEREIRA DOS SANTOS disse em juízo que na época dos fatos recebeu a informação de que três pessoas conhecidas como "Alemão", "Bolívia" e "Gordinho", realizavam transações de armas e drogas na cidade de Sumaré. O policial passou a realizar buscas nas cidades de Sumaré e Hortolândia, até identificar a casa da pessoa conhecida como "Alemão". No local percebeu grande movimentação de veículos e frequente presença de "Gordinho" e "Bolívia". O policial permaneceu de campana nas proximidades do imóvel, juntamente com a sua equipe, e no dia da prisão dos réus avistou Waleff chegando no local com um veículo, conversando com "Alemão" e viu que este atirou um pacote no interior do veículo de Waleff, saiu do local, mas foi perseguido pelos policiais e abordado. Os policiais retornaram à residência do Alemão, onde localizaram grande quantidade de drogas e dinheiro. A embalagem recebida por Waleff continha maconha, e estava embalada com fitas vermelhas, iguais às encontradas na residência de Alemão. O "Alemão" foi abordado e preso também, sendo identificado como sendo o réu Ariovaldo. Nas campanhas realizadas foi visto Wallace com o acusado.

No mesmo sentido foram as declarações do policial ALESSANDRO ALVEZ RIBEIRO.

Neste passo, como já declarou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus depoimentos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem em defesa coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286), e, ainda, "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a

intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente "(RT 614/275). Além disso, inexistente qualquer razão comprovada e justificada para retirar a credibilidade destes depoimentos policiais, os quais se mantêm válidos e aptos a sustentarem decreto condenatório.

Confirmando os depoimentos policiais há o relatório de fls. 263/292.

JESIAS GABRIEL DE SOUZA disse em juízo que conhecia Ariovaldo há cerca de dez anos, pois trabalhou com ele. Reside no bairro próximo ao de Ariovaldo, não sabe se o réu faz uso de drogas, mas tem conhecimento de que a inquilina do réu faz uso de entorpecente. Não presenciou os fatos.

Os acusados negaram a prática do crime.

O réu WALEFF MONTEIRO DE MOURA negou a autoria do crime. Relatou que na verdade realizou apenas uma compra e venda de telefone celular com o réu Ariovaldo, e no dia que foi à residência dele para buscar o ia que seria utilizada para fabricar anabolizantes. Negou que tenha levado os policiais à residência de Ariovaldo e relatou que o conheceu cerca de dez dias antes de ser preso.

O réu ARIovaldo APARECIDO DE SOUZA negou a autoria do crime. Disse que no dia dos fatos os policiais adentraram à sua casa e o acusaram de guardar drogas no imóvel, relatando que havia grande movimentação de pessoas naquele local. O réu justificou a movimentação de pessoas, dizendo que o seu filho possui uma oficina nos fundos da casa, além de ter uma inquilina que ali reside. Acrescentou que a maconha apreendida pelos policiais foi encontrada no seu quintal, e não dentro do imóvel. E quanto ao dinheiro, afirmou que havia retirado do banco e era proveniente da venda de um automóvel.

Este contexto probatório autoriza o reconhecimento de que os acusados praticaram os delitos, sendo irrelevante a falta de conclusão do laudo grafotécnico nas anotações apreendidas na cada do acusado Ariovaldo.

De fato, pela prevalência dos imparciais depoimentos policiais em relação à isolada afirmação dos acusados e sem qualquer prova do alibi destes, autoriza o reconhecimento de que os acusados estavam na posse do material ilícito mencionado na denúncia.

O acusado Ariovaldo foi visto repassando para o acusado Waleff embalagem que em seguida foi identificada contendo material entorpecente e produtos químicos destinados à preparação de entorpecente, tendo sido apreendido na casa de Ariovaldo, ainda, material entorpecente, além de rolo de fita vermelha igausi aquelas que embalavam o material ilícito apreendido com Waleff .

A traficância do acusado Ariovaldo é evidenciada por ter fornecido as drogas e os produtos químicos apreendidos na posse do acusado Waleff, além da quantidade elevada (cerca de 157g de maconha e mais de um quilo de produtos químicos).

Já a traficância do acusado Waleff é depreendida da quantidade elevada da droga e a posse dos produtos químicos, o que indica com clareza a intenção de traficância.

Vale consignar que: "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (TJSP - Ap. nº 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013).

Os acusados então praticaram dois delitos, a conduta do art. 33, caput, da Lei de

Drogas e art. 33, par. 1o, da Lei de Drogas, consignando-se que: " Constatado no laudo definitivo a presença de lidocaína e cocaína, substâncias utilizadas na preparação de drogas, caracteriza-se o delito previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/06, sendo, portanto, indevido o trancamento da ação penal sob o fundamento de atipicidade material da conduta."(STJ - RHC 95926 / SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 19/06/2018), e, ainda, que, não existe desdobramento logico entre a droga apreendida (maconha) e os produtos químicos destinados 'a preparação da cocaína, havendo a autonomia dos delitos:" Se não for possível ver nas ações ou atos sucessivos ou simultâneos nexos causal, teremos, então, delitos autônomos. Por exemplo, se alguém importa matéria-prima destinada à preparação de entorpecente (art. 33, §1º, I), produz entorpecente com essa matéria prima e depois o vende, a violação penal será única; se, todavia, alguém prepara em sua residência substância que determine dependência física ou psíquica, v.g., o LSD e, concomitantemente, exerce o comércio de cigarros de 'maconha', as violações serão duas, porque independentes, e uma não pode ser havida como consumida ou fase de execução da outra." (GRECO, Vicente. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 67).

Assim, os delitos são autônomos entre si, e porque praticados com dolos distintos e com condutas distintas, deve, no caso dos autos ser reconhecido o concurso material de infrações.

Caracterizado os crimes descritos na denuncia, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Para cada um dos acusados, a pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a especial circunstância de se tratar parte da droga apreendida de maconha, entorpecente este que causa dependência química, vulnerando com maior intensidade a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila, impondo-se a exasperação da pena. A elevada quantidade de droga apreendida, suficiente para a intoxicação de dezenas de usuários de drogas também justifica a elevação da pena. A jurisprudência corrobora este entendimento:" A natureza e a quantidade da droga apreendida, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, são circunstâncias que, por si só, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - HC n.º 165.387/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 8-2-2011, DJe 21-2-2011). Fixo, em razão destas circunstâncias, a pena-base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal.

Pela reincidência (fls. 57/58 - Waleff; fls. 66-68 - Ariovaldo) elevo a pena de ambos para 7 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sobre o redutor do art. 33, §4o, da Lei de DROGAS, tem-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além dos maus antecedentes e reincidência dos agentes, afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao crime do art. 33, §1o, da Lei de Drogas, fixo para cada um dos acusados a pena-base no mínimo legal, perfazendo 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que elevo para 6 anos de reclusão e 500 dias-multa pela reincidência de ambos, ficando afastado o trafico privilegiado pelos maus antecedentes de ambos.

Pelo concurso material de infrações, como as reprimendas, a teor do art. 69 do Código Penal, perfazendo a pena final para cada um dos acusados em 13 anos de reclusão e 1000 dias-multa.

Para ambos os acusados, o regime de cumprimento de pena será o inicial fechado,

tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, a reincidência e maus antecedentes, a quantidade de pena cominada, e, ainda, a circunstância do crime de tráfico de drogas ser por demais grave, sendo certo que atualmente é o crime que mais vêm gerando violência no país, impondo-se reconhecer a necessidade da fixação do regime de cumprimento de pena mais rigoroso.

Em atendimento ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, consigna-se que o tempo de prisão provisória em nada altera a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de prova acerca dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios legais, que deverão ser buscados junto ao juiz das execuções criminais (art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR WALEFF MONTEIRO DE MOURA e ARIIVALDO APARECIDO DE SOUZA à pena cada um de 13 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1000 dias-multa, no mínimo unitário, por infração ao art. 33, §10, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Não poderão os réus recorrerem em liberdade porquanto responderam ao processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da prisão decorrente do flagrante a fim de garantir a ordem pública contra novos atentados à saúde pública.

A proibição ao direito de recorrer em liberdade aos réus que respondem presos à instrução vem sufragada pela doutrina como se depreende da lição do jurista Guilherme Nucci: "Réu que aguardou preso a instrução: deve continuar detido, após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado ou o semi-aberto. Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação."

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser acolhida, pois, além da quantidade de pena cominada, em se tratando de delito gerador de violência social e familiar, e pelo princípio da suficiência, incide o entendimento jurisprudencial pelo qual: "como se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, não concedo o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime."(TJSP - Apelação nº 0021376-71.2012.8.26.0309 - Jundiaí - Rel. Des. Alex Zilevoski, j. 8.4.13).

Com o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Recomende-se os acusados no local em que se encontram recolhidos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais.

Declaro a perda em favor da União dos bens apreendidos nos autos, pois vinculados ao tráfico de drogas.

P.R.I.

Sumare, 06 de junho de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito